

1501430-50.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas por falta de provas e quanto ao crime de tráfico de drogas a absolvição do corréu Ezequiel ou subsidiariamente o reconhecimento do tráfico privilegiado e quanto ao corréu Wallace a fixação de pena mínima (fls. 311/319 e 329/350).

É o relatório.

DECIDO.

Primeiro não há que se falar em nulidade no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-400

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501430-50.2021.8.26.0559 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501430-50.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266189/2021 - GOE-DEIC-DEINTER 5, 20555042 - GOE-DEIC-DEINTER 5, 156/21/574 - GOE-DEIC-DEINTER 5, 2266189 - GOE-DEIC-DEINTER 5

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EZEQUIEL ROBERTO BOLDRIN e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Vistos.

EZEQUIEL ROBERTO BOLDRIN e WALLACE RAFAEL BOLDRIN, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados por infração ao artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11343/2006 e combinados com o artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, em concurso material de infrações, porque, segundo narra a denúncia, em data

incerta e perdurando até o dia 29 de setembro de 2021, nesta cidade e comarca, os acusados se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas e também porque no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 10h30min, na Rua General Osório, nº 2199, nesta cidade e comarca, os acusados, com a finalidade de venda, entrega e fornecimento a terceiros, mantinham em depósito 13 porções de maconha (tetrahidrocannabinol), pesando 93,68 gramas, 1 porção de crack (cocaina na forma de pedras de crack), pesando 0,13 gramas, 110 comprimidos da cor laranja de tenanfetamina (MDA), pesando 47,18 gramas, 60 comprimidos da cor rosa de tenanfetamina (MDA), pesando 23,33 gramas e 2 porções de metilenodioximetanfetamina (MDMA), pesando 35,78 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além 1 embaladora a vácuo com resquícios de droga; 1 rolo de plástico tipo "filme"; 1 rolo de plástico usado para embalar a vácuo; 1 balança digital; 1 tesoura de cabo preto; 1 faca de cozinha com cabo preto de plástico; 1 fita de empacotamento parcialmente utilizada; 1 chave de fenda com cabo de plástico verde; diversas unidades de sacos tipo "zip" de diversos tamanhos; 1 simulacro de arma de fogo tipo revólver de cor prata; 1 caixa de som "aberta" de cor preta; 1 telefone celular marca "Motorola, cor dourada, com capa transparente; e R\$ 829,00 (oitocentos e vinte e nove reais) em dinheiro.

Narra a denúncia que policiais receberam informações de que um homem branco, alto, com uma perna mecânica estaria armazenando drogas na casa dos fundos, localizada na Rua General Osório, nº 2199, nesta cidade, bem como que um homem de aproximadamente 50 anos de idade estaria desempenhando a função de segurança do local. Para constatar a veracidade da notícia os policiais iniciaram investigações e, depois de acompanhar o local e realizar campanhas, apuraram que o acusado Wallace, conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, que possui deficiência em uma das pernas, frequentava constantemente o local, em atitude suspeita, e que na casa residia Ezequiel, que era o responsável pela guarda do imóvel (imagens - fls. 4/5 dos autos nº 1505427-87.2021.8.26.0576). Narra que diante disso foi expedido mandado de busca e apreensão (autos nº 1505427-87.2021.8.26.0576) e, no dia 29 de setembro de 2021, policiais permaneceram de campana no local dos fatos até que Wallace chegou na casa e foi abordado, e em seguida, Ezequiel, que é tio e Wallace, também chegou ao local, sendo feita sua abordagem; ato contínuo, realizadas buscas pela casa, os policiais localizaram uma caixa de som grande, e em seu interior, 13 porção de maconha, 170 comprimidos de "Ecstasy", 2 porções de MDMA - Metilenodioximetanfetamina e 1 porção de crack; que no local ainda foram apreendidos 1 embaladora a vácuo com resquícios de droga, 1 rolo de plástico tipo "filme", 1 rolo de plástico usado para embalar a vácuo, 1 balança digital, 1 tesoura de cabo preto, 1 faca de cozinha com cabo preto de plástico, 1 fita de empacotamento parcialmente utilizada, 1 chave de fenda com cabo de plástico verde, diversas unidades de sacos tipo "zip" de diversos tamanhos, e 1 simulacro de arma de fogo tipo revólver de cor prata, além do aparelho celular dos acusados e a quantia em dinheiro, fruto do tráfico ilícito. Narra que indagado, Wallace admitiu ser o "Patrão" da droga e que Ezequiel realizava a guarda do entorpecente para ele, o que foi confirmado por Ezequiel, mas perante a autoridade policial Wallace negou ser o proprietário da droga e Ezequiel disse que realmente era guardião do entorpecente, mas que o realizava para terceira pessoa, não para o sobrinho Wallace. Narra que os diversos tipos de droga que os acusados mantinham em depósito eram daqueles considerados de alto padrão e podem chegar a custar R\$ 200,00 cada grama. Narra que os acusados realizavam a traficância durante estado de calamidade decretado em razão da pandemia do Coronavírus.

Notificados (fls. 169/171), os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 165/166). Recebida a denúncia (fls. 174/177), foram citados. Durante a instrução, depois de ouvidas as testemunhas, os acusados foram interrogados (fls. 295/301).

A instrução foi encerrada e em alegações finais o Ministério Público reiterou o pedido condenatório contido na denúncia, ao passo que a Defesa sustentou, em preliminar, nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão e, no mérito, a

absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas por falta de provas e quanto ao crime de tráfico de drogas a absolvição do corréu Ezequiel ou subsidiariamente o reconhecimento do tráfico privilegiado e quanto ao corréu Wallace a fixação de pena mínima (fls. 311/319 e 329/350).

É o relatório.

DECIDO.

Primeiro não há que se falar em nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão. O mandado foi cumprido durante o dia e o morador, o réu Ezequiel, não estava lá, chegando posteriormente. Todavia, o início do cumprimento somente ocorreu quando da chegada do corréu Wallace, sob quem pesava as denúncias da prática ilícita.

Vê-se da leitura do §4º do artigo 245 do CPP que se trata de recomendação a intimação de vizinho quando ausente os moradores. Ora, como afirmado, acompanhou a diligência sobrinho do morador e investigado, logo, desnecessária a presença de vizinhos. Ademais, a defesa não comprovou o prejuízo.

Afastada a preliminar, passo à análise do mérito.

Na fase extrajudicial acusado EZEQUIEL confirmou que na data dos fatos, por volta das 10 horas, chegou em sua residência, onde já se encontravam seu sobrinho WALLACE e policiais civis. Prontamente foi cientificado acerca do mandado de busca destinado a sua casa, local onde foram recolhidas 13 porções de maconha, 170 comprimidos de ecstasy, 02 pedras e fragmentos de "MD", tudo escondido dentro de uma caixa de som pequena. O interrogando ainda trazia consigo, em seu bolso da bermuda, 01 pedra de crack e também foram apreendidos petrechos voltados ao tráfico, dentre os quais: centenas sacos de plástico, tipo zip, máquina de embalar a vácuo e 01 balança digital. Afirmou que guardava as substâncias entorpecentes e os objetos apreendidos para terceira pessoa, mas não soube precisar o endereço ou qualificação. Os utensílios estavam em sua residência há cerca de 03 semanas, pouco antes de ser internado na Clínica de Recuperação de Drogados de Jaci/SP. Isentou o sobrinho de qualquer envolvimento com o crime. Interrogado em Juízo o acusado Ezequiel afirmou ser usuário de crack. Quando dos fatos estava internado numa clínica de recuperação na cidade de Jaci, saindo naquele dia apenas para consumir droga. Indicou que nada sabia sobre as drogas apreendidas, sendo que seu sobrinho Wallace também estava morando no local. Frisou que se tivesse conhecimento da droga já teria usado, pois se considera um "nóia". Trabalha na confecção de joias e possui sua própria renda. Permaneceu internado na clínica do dia 14 de setembro até a sexta-feira antes dos fatos e nesse período apenas Wallace ficou no imóvel. Já permaneceu internado em clínicas semelhantes em outras ocasiões. Na data dos fatos, chegando em sua casa, deparou-se com os policiais já no interior do imóvel. Entrou em pânico com a situação.

Na fase policial o acusado WALLACE disse que naquele dia, por volta das 10 horas, foi até a casa de seu tio Ezequiel para visitá-lo, como de costume, no entanto, assim que chegou já foi abordado por policiais civis. Na residência, enquanto aguardava no corredor, tomou ciência que foram encontradas diversas porções de maconha, ecstasy, bem como diversos petrechos voltados ao tráfico. Negou ser o proprietário das substâncias entorpecentes, insistindo que estava ali apenas para visitar seu tio. Em Juízo mudou sua narrativa, assumindo a propriedade de todos os entorpecentes e isentando seu tio Ezequiel de qualquer participação. Esclareceu que as drogas estavam escondidas dentro de uma caixa de som e Ezequiel não tinha conhecimento. Justificou que sofreu um acidente e acabou tendo uma perna amputada, razão pela qual passou a consumir mais entorpecentes e não conseguindo manter seu vício passou a vender entorpecentes. Estava morando no local e vendia drogas há aproximadamente três meses. Já tinha sido abordado pelos policiais. Frisou que as

drogas e petrechos estavam escondidos na caixa de som, sem o conhecimento de Ezequiel. Confirmou que Ezequiel é usuário de drogas e já permaneceu internado em clínicas de reabilitação.

Os policiais Humberto Vinicius Lopes e Leonardo Brito Amaral Pereira, no auto de prisão em flagrante, afirmaram que após investigações de tráfico de drogas, que durou aproximadamente dois meses e ensejaram no mandado de busca domiciliar (1505427-87.2021.8.26.0576), notaram que Ezequiel estava associado a Wallace na traficância e era responsável pela guarda, proteção e fracionamento do entorpecente. No curso das investigações ficou evidenciado que Ezequiel trabalhava para Wallace, visto que a droga comercializada por Wallace é de alto padrão e pode chegar a custar R\$ 200,00 cada grama, sendo que o salário de Ezequiel não daria para custear aluguel e alimentação, não tendo como arcar com os custos do entorpecente encontrado. Apuraram que Ezequiel recebia de Wallace as diretrizes para recebimento, guarda e fracionamento do entorpecente conforme o "patrão" mandava. Na data dos fatos a equipe permaneceu de campana e assim que Wallace chegou no "buraco" foi abordado. Em seguida Ezequiel também chegou e ambos foram conduzidos ao interior da residência, onde, após buscas no local foi localizada uma caixa de som grande e o seu interior recheada de entorpecentes, bem como balança de precisão, máquina de embalar e tesoura usada no fracionamento da droga. No interior da caixa de som havia cerca de 13 tipos diferentes de maconha Gourmet, MD e 170 comprimidos de Ecstasy. Afirmaram que os dois acusados confirmaram que a droga era de Wallace e Ezequiel era o responsável pela guarda.

No mesmo sentido são as declarações dos policiais na fase judicial, reiterando a narrativa acima, acrescentando o policial Humberto que a droga apreendida já estava fracionada. A investigação durou entre um e dois meses, o local era ponto de armazenamento das drogas e havia movimentação suspeita. Ezequiel sempre era visto no imóvel, mesmo porque lá residia. Afirmou que durante a abordagem e localização das drogas o acusado Ezequiel acabou confessando os fatos. Frisou que a droga era de alto custo e Wallace já era conhecido nos meios policiais por tal prática. O policial Leonardo também afirmou que durante a abordagem Wallace acabou assumindo a propriedade das drogas e petrechos, sendo que Ezequiel indicou o sobrinho como sendo o "patrão", afirmando que apenas auxiliava na traficância, dividindo, embalando e armazenando os entorpecentes no local.

O policial Eduardo Roberto Conceição, subscritor das informações que embasaram o pedido de busca e apreensão (fls. 3/6 dos autos em apenso), relatou que durante as investigações receberam informações de um homem branco, magro, alto, que utilizava uma perna mecânica, estaria armazenando drogas no endereço local dos fatos. Apuraram que naquele endereço residia um indivíduo de aproximadamente 50 anos, o qual seria pago para fazer a segurança da droga ali armazenada. Efetuaram diligências nas proximidades, identificando o homem branco como sendo Wallace, conhecido nos meios policiais por envolvimento com o narcotráfico. O outro indivíduo não foi identificado, contudo, reside no local, seria o responsável por guardar a drogas e foi avistado diversas ao lado de Wallace. Ouvido em Juízo a testemunha confirmou as investigações prévias, que duraram cerca de dois meses, com diversas campanas, na qual era visto o corréu Ezequiel. Participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão, confirmando a apreensão de diversas drogas e petrechos no imóvel. Ficou com a impressão de que Ezequiel dependia financeiramente do sobrinho Wallace.

Gabriel Santos disse que deu uma carona ao amigo Wallace para visitar o tio. Quando chegaram já foram abordados pelos policiais e levados para o interior do imóvel. Confirmou que os policiais localizaram drogas dentro de uma caixa de som.

Valmir Santos não presenciou os fatos, sendo apenas de referência. Ouviu comentários de que Ezequiel era usuário de crack.

Ante o exposto, pela prova do feito, angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de rigor a condenação.

A materialidade é comprovada pelos documentos de fls.1/19 (auto de prisão em flagrante), fls.156/160 e 184/229 (laudos periciais) e pela prova oral.

De igual forma a autoria restou comprovada, recaindo nas pessoas dos acusados. A prova dos autos demonstra que os entorpecentes apreendidos pertenciam aos acusados, se destinavam ao comércio ilícito e não apenas ao consumo próprio, mormente pelas condições da abordagem, diversidade e quantidade das drogas apreendidas.

Ressalte-se a confissão policial do corréu EZEQUIEL de que guardava as drogas, na qual estava assistido por advogado constituído, pois a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que a confissão e delação feitas na fase extrajudicial possuem eficácia probatória, desde que corroboradas por outras provas colhidas na fase de instrução processual, como é o caso dos autos. Nesse sentido: "Processo penal. Prova. Confissão extrajudicial. Posterior retratação judicial. Eficácia probatória da confissão realizada perante a autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar onde é prestada, mas por seu próprio teor, sempre que confirmada pelo restante do conjunto probatório. Processual Penal. Prova. A delação do corréu deve ser considerada como prova, sempre que ele assume sua participação na empreitada, não tentando se eximir de sua responsabilidade" (TJSP, Apelação Criminal nº 0007584-73.2009.8.26.0400, Rel. Des. Souza Nery, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 29/11/2012).

Temos ainda a confissão judicial do corréu WALLACE, merecendo destaque a lição sempre atual de Júlio Fabbrini Mirabete, segundo o qual: "...a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (MIRABETE, Júlio Fabbrini. - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo: Atlas, 2003, p. 288). No mesmo caminho segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste estado: "A confissão judicial, exceto especialíssimas circunstâncias, tem especial valor para o deslinde da causa, mormente quando se encontra em consonância com os demais elementos de convicção coligidos no processo, sob o crivo do contraditório, não pairando dúvidas quanto à prática delitosa e à autoria atribuída aos apelantes. Assim, é o que basta para a fundamentação da sentença condenatória, ainda que fosse a confissão o único elemento incriminador a pesar em desfavor dos réus, somente perdendo sua força se contrariada pelas provas colhidas em juízo, o que não é o caso." (Apelação Criminal 990.09.274150-0 - 14ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Dês. Marco Antônio de Lorenzi - Data de registro 23/04/2010).

Além do mais, temos as narrativas uníssonas e coerentes dos policiais, afirmando que durante a investigação apuraram como de fato se dava a dinâmica do tráfico de drogas no local dos fatos, identificando os acusados nas incursões realizadas, inclusive com imagens capturadas (fls. 3/6 - autos em apenso), apurando a participação de cada um deles. Temos ainda a apreensão dos diversos petrechos, inclusive balança de precisão e embaladora, instrumentos notadamente usados em crimes do tipo. Vale destacar as narrativas incisivas dos policiais, no sentido de que os acusados confessaram a prática delitiva, não havendo notícia de tivessem motivos para acusá-los falsamente. Ademais, tais relatos estão fortemente amparados no restante da prova produzida, destacando as diversas mensagens/imagens coletadas do celular apreendido (fls.193/229).

Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de vida dos acusados, no caso, não tendo sido trazidos aos autos elementos que conduzam à certeza quanto à possibilidade de poderem incursionar pela seara do uso de drogas. Também não foi

comprovada a origem lícita do numerário apreendido.

Além do mais, pode coexistir, na mesma pessoa, a figura de traficante e usuário. O fato de serem usuários de substância entorpecente não obsta ao reconhecimento da figura de traficante. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilitar-se-á o emprego na compra, para que o vício possa ser sustentado.

É certo que na primeira vez que foram ouvidos o corréu Ezequiel assume sozinho a prática delitiva e em Juízo a situação se inverte, mas isto é mais uma prova que os dois guardavam as drogas e os petrechos. Ademais, o fato de o réu Ezequiel ter permanecido em casa de recuperação não afasta a conclusão acima. As investigações perduraram por cerca de dois meses, muito antes de daquele corréu ser internado na clínica de recuperação.

Quanto ao valor dos depoimentos de policiais, servidores públicos, fielmente compromissados com o bem e a defesa da coletividade (o dever funcional de um policial, em sentido estrito, é prevenir e reprimir o crime). Assim, presume-se que agem corretamente e são dignos de credibilidade, mormente porque não há nos autos nenhuma notícia de que teriam motivos para acusá-los falsamente.

Para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “Os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o réu, por tráfico ilícito de entorpecentes, gozam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam as provas testemunhais. Apenas porque são policiais não estão não impedidos de depor, tampouco possuem tais depoimentos pequeno valor, sobretudo se os mesmos estão em harmonia com as demais provas dos autos, inclusive com a delação dos usuários da fase inquisitorial” (Ap. 20030110632367APR, 1ª T., Rel. Edson Alfredo Smaniotto, 09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p. 180).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada” (HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304).

Vale ressaltar ainda que para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, basta a ocorrência de um dos verbos do tipo penal (descrição da lei), o que, neste caso, constitui o fato de os réus armazenarem os entorpecentes apreendidos, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No tocante ao crime de associação, as provas produzidas também são suficientes para concluir que os acusados estavam associados entre si, reiteradamente ou não, com a finalidade de traficar entorpecentes.

Como visto acima, ficou provado que as drogas eram adquiridas pelo corréu WALLACE e guardadas pelo corréu EZEQUIEL em seu imóvel. Relatório policial, com fotos, aliado

ao depoimento dos policiais, não deixam dúvidas que o local dos fatos era utilizado para guardar as drogas adquiridas pelo corréu Wallace. Periciado o celular do acusado Wallace foram encontradas diversas mensagens, áudios e fotos comprovando seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Em suma, ficou comprovado que eles se dedicavam ao narcotráfico, com funções definidas, não se tratando de mero concurso de agentes.

Com efeito, para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se pluralidade de agentes, duas ou mais pessoas, ligadas entre si por um animus associativo, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de entorpecentes. No caso, ficou suficientemente provado que os réus estavam associados entre si, para fins de tráfico de drogas.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, para o crime de tráfico, fixo as penas em 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa, no mínimo a unidade. Para tanto levo em consideração a natureza, diversidade e quantidade de drogas apreendidas ("13 porções de maconha (tetrahydrocannabinol), pesando 93,68 gramas, 1 porção de crack (cocaína na forma de pedras de crack), pesando 0,13 gramas, 110 comprimidos da cor laranja de tenanfetamina (MDA), pesando 47,18 gramas, 60 comprimidos da cor rosa de tenanfetamina (MDA), pesando 23,33 gramas e 2 porções de metilenodioximetanfetamina (MDMA), pesando 35,78 gramas"). Já para o crime de associação para o tráfico fixo no mínimo, em 3 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, no mínimo a unidade.

Na segunda fase, quanto ao corréu WALLACE, incide a agravante da reincidência específica (fls. 292), todavia, fica compensada com a atenuante da confissão espontânea. Deixo de considerar a atenuante da confissão espontânea para o corréu Ezequiel porque houve retratação em Juízo.

Quanto à compensação entre a reincidência e a confissão saliento que o E. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585 firmou a tese que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência" e o relator do tema, Min. Sebastião Reis Junior, proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, decidindo: "Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

Deixo de considerar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal em razão de não ter ficado comprovado que a calamidade pública causada pela pandemia do Covid-19 tenha facilitado ou influenciado de qualquer forma na prática dos crimes.

Na terceira fase descabida a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Ora, neste caso, o acusado

WALLACE ostenta outra condenação, sendo reincidente específico e ainda está sendo condenado pelo crime de associação, logo, fica afastada a aplicação do redutor.

Vale ressaltar que a reincidência deve ser utilizada tanto para agravar a pena na segunda fase, como para afastar a incidência do redutor previsto na Lei de Drogas e isto não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem, conforme reiteradas decisões do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. ÚNICA CONDENAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA E NEGAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MODO FECHADO ADEQUADO. DETRAÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO À INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

3. Reconhecida pela Corte de origem a reincidência do paciente, torna-se incabível a aplicação da mencionada benesse, porquanto não preenchidos os requisitos legais. Precedente.

4. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ainda que decorrente de apenas uma condenação transitada em julgado, pode ser utilizada para agravar a pena e, concomitantemente, para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem se falar em bis in idem. Precedentes.

(...)

7. Habeas corpus não conhecido” (HC 391152/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 18/04/2017, De 25/04/2017, grifo meu).

Com relação ao corréu EZEQUIEL também restou comprovado que se dedicava a atividades delituosas, afastando a aplicação do redutor. Com efeito, o acusado está sendo condenado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Com efeito, o legislador, ao editar a lei de drogas, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, conseqüentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Em outras palavras, para a situação do mercador novato, aquele de pequena expressão, conhecido como “traficante de primeira viagem”, como se pode classificar aquele que possui “estoque” diminuto para negociar durante curto período e, em regra, suprir o próprio vício. Portanto, para esse tipo de traficante é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu maior rigor punitivo.

A doutrina e a jurisprudência apontam situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o agente estar respondendo a outros processos criminais, encontrar-se na posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens para porções individualizadas, balanças de precisão ou, ainda, quantidade e variedade de drogas apreendidas.

Com efeito, a par da primariedade de EZEQUIEL, a própria dinâmica fática, as investigações que perduraram cerca de dois meses e a condenação por associação ao tráfico de drogas afastam a condição de traficante ocasional, sujeito ativo a quem a lei objetiva emprestar tratamento diferenciado. Não se olvide ainda a apreensão de petrechos a comprovar também a dedicação a atividades criminosas.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, ficam definitivas as penas, que

somadas resultam em 09 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 1366 dias-multa.

Fixo o regime inicial para o cumprimento da pena de prisão no fechado. As penas superam oito anos e o corréu Wallace é reincidente. Aliás, foram surpreendidos armazenando grande quantidade de drogas diversas e petrechos, de sorte que a gravidade concreta do delito se revela totalmente incompatível com regimes menos gravosos.

Ressalto que a fixação do regime fechado se faz necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos desta natureza e acautelar o meio social.

Os réus estão presos. Nego o direito ao recurso em liberdade. O crime que cometeram e as penas a que estão submetidos, nesta sentença, são suficientes para retratar suas periculosidades se soltos, de modo que a prisão se sustenta na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ademais, como permaneceram presos durante a tramitação do processo, seria um contrassenso que, sem o primeiro título de condenação, a sentença, houvesse motivo para manutenção do cárcere. E, depois, com a definição da culpa (ou pelo menos a primeira definição rumo à culpa), tivessem o direito de deixar a prisão.

Assim, já se decidiu: "Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. (...) Direito de apelar em liberdade. Réu que permaneceu custodiado ao longo do processo. Prisão preventiva. Fundamentação. I - O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. (Precedentes do STJ e do STF). II - A exigência da prisão provisória para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. (Súmula n. 09 do STJ). (...) III - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantir ao paciente a revogação da prisão cautela (Precedentes). Writ denegado" (HC 62882/RS; Ministro Felix Fischer, j. 07/11/2006, DJ 12.02.2007, p.285).

O presente caso não comporta aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois, com a prisão provisória, ainda não alcançaram o tempo que lhes permitiria a progressão de regime.

Ante ao exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, o que faço para condenar os réus:

EZEQUIEL ROBERTO BOLDRIN como incurso nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.366 dias-multa, no mínimo a unidade; e.

WALLACE RAFAEL BOLDRIN como incurso nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.366 dias-multa, no mínimo a unidade.

Cada dia-multa deverá ser calculado sobre um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato e devidamente corrigida, nos termos do art. 49, do Código Penal.

Como exposto acima, sem direito a recurso em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontram.

Condeno-os ainda no pagamento das custas, no valor de 100 UFESPs, observando-se, contudo, eventual concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Comprovado o tráfico de drogas, decreto o perdimento do numerário, celular e objetos apreendidos, em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, não foi comprovada a origem lícita do bem apreendido.

Agora, com a sentença decretada, estando o laudo definitivo da droga nos autos, determino a destruição da contraprova armazenada, servindo esta como ofício.

Por fim, após o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se à Justiça Eleitoral a suspensão dos direitos políticos do réu (art. 15, inc. III, da Constituição Federal).

P. C. I. C.

São José do Rio Preto, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA